

第3章 違法性／第1節 総論

刑法
No67

H21-3

(配点: 3)

月	日
月	日

次の1から5までの各事例を判例の立場に従って検討した場合、甲に刑法上の犯罪が成立しないものはどれか。

1. 甲は、勤務先の会社内において、同僚乙の同意の下、乙と上司丙を名指しして、両名が不倫関係にあった旨虚偽の事実を記載した文書を、同社の従業員多数の目に触れる掲示板に掲示した。
2. 甲は、乙の同意の下、乙が甲の自動車を盗んだ旨の虚偽の事実を警察官丙に申告し、乙の処罰を求めた。
3. 甲は、乙の同意の下、乙から借り受けた乙所有のコピー機を丙に転貸していたが、同コピー機の修理のため一時これを丙から預かった際、乙の同意の下、丙に無断で、自己の借金の返済として同コピー機を自己の債権者に譲渡した。
4. 甲は、乙の同意の下、乙が丙に賃貸した乙所有の自動車に放火してこれを燃やしたが、公共の危険は生じなかった。
5. 甲は、民事訴訟の証拠調べの期日において、証人として宣誓の上、原告乙及び被告丙双方の同意の下、虚偽の陳述をした。

1 成立する

本事例では、甲が、乙の同意を得て、乙丙を名指しした虚偽の事実を記載した文書を会社内の掲示板に掲示した行為につき、名誉毀損罪（230条1項）が成立するか、被害者乙の同意があることから問題となる。被害者の同意が違法性を阻却するためには、同意の内容が被害者にとって処分可能な個人法益に関するものである必要がある。名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉、すなわち、人に対する社会的評価という個人法益に対する犯罪であり、同意により違法性を阻却することは可能である。よって、甲の行為につき同意を与えた乙については、名誉毀損罪が成立しない。もっとも、行為が1つでも被害法益が個人的法益である場合、犯罪は被害者の数だけ成立する。とすれば、丙についても名誉毀損罪が成立し、これは、丙の同意がない以上違法性が阻却されないの、丙に対する名誉毀損罪が成立する。したがって、本事例においては、甲に丙に対する名誉毀損罪が成立する。

2 成立する

大判大元12.20。本記述における虚偽告訴罪（172条）の成否につき、被害者の同意が構成要件該当性を阻却するためには、同意の内容が被害者が処分可能な個人的法益に関するものである必要がある。しかし、判例は、虚偽告訴罪の保護法益は、被告告訴者の生活の平穏という個人的法益のみならず、無用な捜査等を回避するという国家的法益をも含むとしている（大判大元12.20）。したがって、乙の同意ある虚偽告訴も構成要件該当性が認められ、甲には虚偽告訴罪が成立する。

3 成立しない

本事例では、甲が、修理のため丙から一時預かったコピー機を、コピー機の所有者乙の同意の下、譲渡した行為につき、横領罪（252条1項）の成否が問題になる。横領罪は、個人的法益に対する罪であり、コピー機の所有者である乙が当該処分（代物弁済として甲の債権者に譲渡）について同意を与えているので、構成要件該当性が阻却されるはずである。ここで、コピー機は適法に丙に転貸中のものであり、甲が修理のために一時預かっているにすぎないことから、丙との関係で横領罪が成立しないかが問題となる。この点、そもそも横領罪が成立するためには、客体が他人の物でなければならないが、「他人の物」とは他人の所有権に属することを意味すると解されている。そして、原則としての所有権とは、あくまで民事法上の所有権とされる。この例外規定である252条2項の「公務所から保管を命ぜられた場合」に本事例は該当しない。また、他人の占有する自己物に対して処罰を定める242条や262条の規定は、処罰範囲を拡張する例外規定であり、明文の準用規定のない限り横領罪に適用することはできない（最決昭52.3.25参照）。よって、丙の賃借権を侵害したとしても横領罪は成立しない。したがって、本事例においては、甲に刑法上の犯罪は成立しない。なお、甲の行為が丙に対する背任罪（247条）とならないかが問題となる。この点、背任罪は「他人のためにその事務を処理する者」が主体であり、「その事務」とは、他人すなわち本人の事務をその本人に代わって行うことをいう（大判大3.10.12）。貸主が修理のために預かったコピー機を修理して引き渡すことは借主のためであっても貸主自身の事務（民法606条参照）であり、これを怠っても単なる債務不履行となるにすぎず、背任罪にはあたらない。よって、背任罪は成立しない。

4 成立する ★

本事例では、まず、甲が自動車に放火した行為につき、**建造物等以外放火罪**（110条）の成否が問題となる。この点、公共の危険の発生は建造物等以外放火罪の構成要件要素であるが、本事例では公共の危険が発生していないので、同罪は成立しない。次に、**器物損壊罪**（261条）の成否が問題となるが、本事例では、所有者である乙の同意があるため、個人法益に対する罪である毀棄罪の違法性が阻却されないかが問題となる。この点、自己所有物の処分は本来自由なはずであり、所有者が同意している以上不可罰である。しかし、他人が権利を設定している場合にこれを損壊することは、他人の権利を侵害することになるため、その権利を保護する必要がある（262条参照）。とすれば、本記述においては、乙が乙所有の自動車を丙に賃貸しているので、丙の賃借権を保護する必要があり、乙は有効な同意をなし得ない。したがって、本事例においては、甲に器物損壊罪が成立する。

5 成立する

本記述における偽証罪（169条）の成否につき、被害者の同意が構成要件該当性を阻却するためには、同意の内容が被害者にとって処分可能な個人的法益に関するものである必要があるが、偽証罪は、虚偽の陳述等によって裁判や懲戒処分という国の審判作用を侵害する危険を生じさせる罪として国家的法益に対する犯罪と位置づけられ、被害者が処分可能な個人的法益とはいえない。したがって、原告乙及び被告丙双方の同意によっても構成要件該当性は阻却されず、甲には偽証罪が成立する。